

1501426-75.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcel Peres Rodrigues

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... por si sós, para demonstrar a finalidade do tráfico de entorpecentes pelos acusados. Mas não é só. Em poder de ambos foram encontrados valores sem comprovação de origem lícita, ou seja, o produto do crime, evidenciando, assim, que os réus realmente estavam juntos se dedicando ao comércio espúrio na Viela já conhecida como ponto de tráfico.

Diante dessas circunstâncias, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba - SP - cep 16015-600

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501426-75.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501426-75.2021.8.26.0603

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WABNER MOURA DA SILVA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcel Peres Rodrigues

V I S T O S.

JOSÉ ARMANDO COSTA e WABNER MOURA DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, combinado com o artigo 29, caput, do Código Penal, porque, no dia 12 de outubro de 2021, por volta das 21:20 horas, na Travessa Aguinaldo Ferraz, altura do número 03, no Bairro Alvorada, nesta Cidade e Comarca, previamente ajustados e conscientes da ação comum, traziam consigo, para fins de tráfico, 11,8 gramas de maconha e 30,52 gramas de cocaína, substâncias estas que causam dependência, o que faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os réus foram notificados e apresentaram defesa preliminar a fls. 111/112 e 161/167. A denúncia foi recebida a fls. 173/176. No decorrer da instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e interrogados os acusados (fls. 255/257).

Encerrada a instrução, o Dr. Promotor de Justiça apresentou alegações finais, oportunidade em que requereu a procedência da ação penal nos termos da denúncia e pediu a juntada de laudo complementar do celular apreendido (oralmente, conforme termo de fls. 253), o que foi deferido. Recebido o laudo pericial a fls. 271/276, o Dr. Promotor de Justiça reiterou as alegações finais já apresentadas (fls. 280). A Defesa do acusado Wabner Moura da Silva requereu a improcedência da ação penal, sustentando, em síntese, que a prova é precária. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu grau máximo, a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 283/287). A Defesa do acusado José Armando Costa requereu a improcedência da ação penal sustentando, em síntese, que a prova é precária. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas em seu grau máximo, a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação do regime inicial aberto (fls. 292/295).

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime veio comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, laudos de constatação provisória de fls. 25/26 e exames químicos de entorpecentes encartados a fls. 86/90, que resultaram positivos para maconha e cocaína.

E a responsabilidade dos acusados é indubitosa.

Interrogado em Juízo, o réu José Armando Costa negou a prática do delito. Disse que estava com Wabner saindo da casa da cunhada dele para comprar lanche quando, ao descerem uma rua sem saída, viram dois policiais abaixados, saindo de uma casa abandonada, que foram em sua direção. Os policiais os algemaram, dizendo que estavam presos por tráfico. Em sua posse, encontraram uma balinha de maconha, dois celulares e cinquenta reais. Esclareceu que um dos celulares era de sua filha. Afirmou que na época trabalhava como servente. Presenciou a revista do réu Wabner e disse que não foi encontrada nenhuma droga com ele. No local não lhe foi mostrada droga alguma, a qual só viu na delegacia. É primo de Wabner, que não usa drogas e trabalhava como servente. Confirmou seu depoimento na delegacia, mas esclareceu que só disse que foi encontrado cocaína perto de Wabner por ter sido ameaçado pelos policiais, embora durante o depoimento estivesse acompanhado de seu advogado. Está respondendo a outro processo por tráfico. Por fim, disse que é usuário de drogas e que não conhecia os policiais.

Wabner Moura da Silva, interrogado em juízo, também negou a prática do crime. Disse que estava em sua casa e sua pediu para comprar um lanche. Avistou o corréu José Armando descendo a rua e o chamou para ir junto comprar referido lanche. Neste momento apareceram dois policiais, mas como não percebeu que se tratavam de policiais, se assustou e deu dois passos para trás. Em sua posse foram encontrados apenas R\$ 10,00 (dez reais) e um celular, de sua propriedade. Com o corréu José Armando viu encontrarem apenas dois telefones e a quantia de cinquenta reais. Não viu drogas. Na hora não lhe foi apresentado nada de ilícito, mas viu os policiais pegarem uma sacola com drogas --- microtubos na cor preta com cocaína --- dentro da

viatura. É primo do corréu José Armando. Afirmou não ser usuário de drogas e não soube dizer se José Armando usa entorpecente. Na época dos fatos trabalhava como servente. Morava na Agnaldo Ferraz e não sabe onde o corréu morava. Esclareceu que já foi processado, quando menor, por tráfico. Por fim, disse que não conhecia os policiais.

Ocorre que as versões dos acusados não convencem, pois além de contraditórias --- José Armando disse que estavam saindo da casa da cunhada de Wabner, ao passo que este disse que encontrou José Armando na rua quando saiu de sua casa para comprar lanche para a esposa; José admite o encontro da porção de maconha em seu poder, ao passo que Wabner afirma que viu os policiais encontrando os celulares e o dinheiro com José, mas não a droga---, restaram isoladas no contexto probatório, que os compromete.

De fato, os policiais militares que participaram da diligência prestaram versões harmônicas e coerentes, descrevendo com riqueza de detalhes toda a operação que realizaram e afastando por completo a alegação dos réus de que não estavam praticando o crime de tráfico no local. Ouvidos em Juízo, os policiais Júlio César e Eder afirmaram que no dia dos fatos estavam em patrulhamento e adentraram na Travessa Agnaldo Ferraz, que é uma rua sem saída com uma viela no fundo. Essa viela dá acesso a uma mata com um riacho/córrego e é um local conhecido pela comercialização de drogas. Ao adentrarem na travessa viram os réus saindo por essa viela, os quais, ao avistarem a viatura, se assustaram e tentaram regressar, porém foram imediatamente abordados. Em revista pessoal, o policial Eder localizou com o réu José Armando uma porção de maconha, dois celulares e cinquenta reais em uma única nota. Com o réu Wabner foram encontrados 41 pinos com cocaína, um celular e vinte reais, que estavam divididos em duas notas de cinco reais e uma de dez reais. Questionados no local sobre a droga, ambos confessaram que estariam praticando o tráfico. Após, foi feita uma vistoria no local, mas não foi encontrado mais nada de ilícito. Por fim, disseram que não conheciam os acusados.

E não há porque se colocar em dúvida a versão dos policiais, porque como qualquer outra testemunha eles prestam compromisso de dizer a verdade, e não viriam a Juízo apresentar versão mendaz, apenas para justificar a diligência que realizaram. Note-se que não há nos autos prova de desavença anterior entre os policiais e os réus, de forma que seus depoimentos merecem credibilidade, pois não teriam qualquer motivo para acusarem injustamente um inocente. Não se pode desconsiderar uma prova por mera presunção, sem prova de suspeita ou má-fé, como pretende a Defesa.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“Por sua vez, o art. 207 estabelece quais as pessoas proibidas de depor, o que se dá em razão de função, ministério, ofício ou profissão, não estabelecendo qualquer restrição aos agentes que efetuem a prisão em flagrante no sentido de servirem como testemunhas. Assim, desde que tais depoimentos não se tornem suspeitos ou indignos de fé, têm plena validade em face da lei (TJSP - AC- Rel. Hoepfner Dutra - RT 416/96).

“Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição” (RT 614/2756).

No mais, como já visto, os policiais apresentaram esclarecimentos coerentes e harmônicos, narrando a dinâmica da diligência que realizaram, com riqueza de detalhes, demonstrando de forma cabal a prática do tráfico de entorpecentes pelos

réus.

Destarte, as seguras e harmônicas declarações dos policiais devem prevalecer, não restando dúvida de que os réus traziam consigo os entorpecentes descritos na denúncia. A alegação dos réus de que os microtubos de cocaína teriam sido “plantados” pelos policiais, além de não encontrar qualquer substrato probatório nos autos, foge da razoabilidade, pois não é crível que policiais militares andem com tamanha quantidade de droga em suas viaturas e, pior, que a utilizem para prejudicar pessoas que mal conheciam.

Assim, o conjunto probatório é farto na demonstração de que toda a droga apreendida realmente pertencia aos acusados.

E o destino do entorpecente apreendido em poder dos réus, que são primos, é manifesto, vez que traziam consigo, em um local conhecido como ponto de tráfico, uma considerável quantidade de entorpecentes, ou seja, 30,52 gramas de cocaína, acondicionados em 41 microtubos, prontos para imediata comercialização, e uma porção de maconha pesando 11,8 gramas. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes apreendidas já seriam suficientes, por si sós, para demonstrar a finalidade do tráfico de entorpecentes pelos acusados. Mas não é só. Em poder de ambos foram encontrados valores sem comprovação de origem lícita, ou seja, o produto do crime, evidenciando, assim, que os réus realmente estavam juntos se dedicando ao comércio espúrio na Viela já conhecida como ponto de tráfico.

Diante dessas circunstâncias, tem-se que a finalidade de tráfico de entorpecentes por parte dos réus é evidente.

Neste sentido:

“Levando-se em conta a grande quantidade de entorpecente encontrada, o valor e o escasso poder de compra do acusado, aliando-se ao fato de que levava ao local de serviço, tem-se que está correta a classificação do delito no art. 12 da Lei 6368/76” (TJ-SP – AC 161.748-3-0 – Rel. Gentil Leite – RT 710/279).

“Considerados a quantidade (15g) e o valor da cocaína apreendida, em contraste com a modestíssima renda do recorrente, confirmam a decisão de primeiro grau, que entendeu configurado o delito capitulado no artigo 12 da Lei 6368/76” (TJRS – AC – Rel. Oswaldo Proença – RJTJRS 145/115).

Verifica-se, portanto, que a prova acusatória forma um todo coeso e concorde, perfazendo a necessária certeza para a prolação do decreto condenatório, ante estarem demonstradas, in casu, de forma indubitável, a autoria e materialidade delitiva, afastando-se toda e qualquer tese absolutória.

De rigor, portanto, a condenação dos réus.

Passo a dosar a pena a ser imposta.

Os réus não ostentam antecedentes criminais. Analisando, ainda, as demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal para ambos os réus, ou seja, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria penal, deixo de reconhecer a atenuante da menoridade relativa dos réus, vez que a pena base já foi fixada no patamar mínimo legal e no direito brasileiro “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (Súmula nº 231 do STJ).

Na terceira fase de dosimetria penal, entendo que os réus não fazem jus à causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Isso porque, embora tecnicamente primários, Wabner, poucos meses antes dos fatos, foi condenado ao cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto pela prática de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de entorpecentes (fls. 158/160), ao passo que José Armando, alguns meses após os fatos, foi preso em flagrante pela prática de crime de tráfico, estando respondendo por este novo delito (fls. 230/234 e consulta realizada). Tais circunstâncias, aliadas ao fato de que os acusados não possuem emprego lícito comprovado nos autos, permitem concluir que eles não se tratam de meros traficantes ocasionais, mas sim que se dedicam às atividades criminosas, fazendo do tráfico meio de vida e fonte de renda. Assim, os réus não preenchem os requisitos necessários à concessão do benefício ---“desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa---. Neste sentido: “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. SITUAÇÃO IDÔNEA A SER VALORADA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. QUANTIDADE DE DROGA. USO NA PRIMEIRA FASE E NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. ELEMENTO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Quanto ao pedido de incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, frise-se que, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. III - In casu, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na quantidade e na natureza da droga apreendida: 1.364,77 g de cocaína; e 489,51 g de crack. IV - De mais a mais, o Tribunal de origem afirmou que o paciente "assume funções de chefia e direção em organização criminosa. Acrescente-se que, conforme documento de fl. 52, o réu apresenta inúmeras passagens pela Vara da Infância, fazendo do crime o seu meio de vida desde a adolescência" Com efeito, "a Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes" (AgRg no HC n. 588.716/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 28/08/2020). V - Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Nesse sentido: HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/2/2017; e HC n. 379.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/2/2017. VI - Ainda, insta consignar que é entendimento desta Corte que a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para a elevação da pena-base, e para o afastamento da incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, na terceira fase, não configura bis in idem. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.255.180/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 15/02/2013; HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/2/2017; HC n. 379.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/2/2017; AgRg no REsp n. 1.779.825/RO, Quinta Turma Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/05/2019. VII - Regime inicial. A quantidade e a natureza do entorpecente - 1.364,77 g de cocaína; e 489,51 g de crack - foram utilizadas como fundamentos a

ensejar a aplicação do regime fechado, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, "a", e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Confira-se: HC n. 488.679/SP, Quinta Turma Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/06/2019; e AgRg no HC n. 380.021/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 22/3/2017. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 641.285/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DEFESA PLEITEIA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E A MANUTENÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – O MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVA QUE SEJA ELEVADA A PENA-BASE, AFASTADA A INCIDÊNCIA DO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006, FIXADO O REGIME FECHADO E CASSADA A SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS – COM INTEIRA RAZÃO O MINISTÉRIO PÚBLICO – PENAS ALTERADAS – RÉU PRIMÁRIO, MAS COM PASSAGEM ANTERIOR PELA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – DEDICAÇÃO AO NEFASTO COMÉRCIO DEMONSTRADA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO AFASTADA – IMPOSSIBILIDADE DE PERMUTA E DE RIGOR O REGIME FECHADO, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DE EMPREITADA CRIMINOSA – A MULTA NÃO PODE SER REDUZIDA, POIS JÁ SE ENCONTRA NO MÍNIMO LEGAL – EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DEVE SER EXAMINADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal nº 1500927-84.2019.8.26.0628; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Taboão da Serra – Vara Criminal; Des. Relator: Euvaldo Chaib; Data de Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 24/09/2020). "Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Preliminar – O indeferimento do pedido de realização de exame de dependência toxicológica não configura cerceamento de defesa – Ausência de elementos que indicassem qualquer comprometimento da capacidade cognitiva – Preliminar rejeitada – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de porções de cocaína em poder do acusado – Fator que, associado à prova produzida, leva à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Regime inicial fechado mantido – Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Justiça Gratuita – Questão a ser apreciada pelo Juízo da Execução – Rejeitada a preliminar, recurso de apelação desprovido. Apelação da Justiça Pública – Exasperação da pena-base – A despeito da natureza da droga apreendida, a quantidade de entorpecente não justifica a elevação da pena, com fulcro no artigo 42 da Lei de Drogas – Afastamento da causa de diminuição de pena prevista o artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 – Redução que deve se voltar às hipóteses em que o acusado não faz da narcotraficância seu meio de vida – Acusado que responde a outra ação penal pela prática do mesmo crime e voltou a delinquir após a concessão da liberdade provisória – Recurso de apelação parcialmente provido." (TJSP; Apelação Criminal 1500140-96.2020.8.26.0603; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/03/2021; Data de Registro: 01/03/2021).

"1-) Apelação Criminal. Tráfico ilícito. Recurso defensivo não provido. 2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Tráfico caracterizado, a impedir o acolhimento do pleito de desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/06. Negativa de autoria infirmada pelos insuspeitos depoimentos de policiais militares. 3-) A dosimetria está correta. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no patamar mínimo, isto é, cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, inexistentes agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não pode incidir. O apelante é jovem e tecnicamente primário, no entanto, estava com quantidade razoável de droga, 55 unidades de cocaína e "maconha", além de responder a outro processo por delito de mesma natureza, estando em liberdade provisória apenas há três meses, o que mostra sua tendência delitiva, dedicação à ação criminosa. Pena final: cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, no patamar mínimo. 4-) Não se substitui a pena, pois ausentes os seus pressupostos. 5-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pelas circunstâncias, pela gravidade concreta do crime e periculosidade, para sua efetiva prevenção geral e

especial, além da retribuição e recuperação. 6-) Custódia cautelar mantida. A prisão é necessária, pois existe condenação por r. sentença, com regime inicial fechado, tendo-se a necessidade do encarceramento para a manutenção da ordem pública e da aplicação a lei penal." (TJSP; Apelação Criminal 1501204-44.2020.8.26.0603; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª

Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/03/2021; Data de Registro: 11/03/2021 ---destaquei). Ausentes outras circunstâncias modificadoras de reprimenda, torno definitiva a pena aplicada, calculada a de multa no patamar mínimo legal.

Portanto, ante a ausência de circunstâncias modificadoras, torno definitiva a pena aplicada.

O valor do dia-multa, ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica dos réus, será calculado no seu valor unitário mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de condenar JOSÉ ARMANDO COSTA e WABNER MOURA DA SILVA, qualificados nos autos, ao cumprimento de cinco anos de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a quinhentos dias-multa, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, combinado com o artigo 29, "caput", do Código Penal.

O regime para o cumprimento de pena, para ambos os réus, é o inicial fechado, justificável diante da latente e concreta gravidade do crime (os acusados se dedicam ao tráfico de drogas, não se tratando o crime em questão do chamado "tráfico privilegiado", como já visto), fomentador de tantas outras práticas ilícitas, restando evidentemente prejudicada a aplicação da Lei nº 9.714/98, mesmo porque os objetivos do legislador com a promulgação desta Lei demonstram que ela afeta apenas aos crimes menos graves, distanciam-se em muito da hedionda mercancia.

Demais disso, ainda que alguns requisitos do artigo 44, do Código Penal fossem favoráveis aos réus (o que não é o caso, visto que a pena aplicada é superior a quatro anos de reclusão), não estaria configurado o previsto pelo inciso III, in fine, do mencionado dispositivo legal, ou seja, "os motivos e circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente". O traficante é um grande responsável direto pela onda de violência que avassala o país. No caso concreto, a insuficiência da substituição em tela para a repressão e prevenção do tráfico ilícito de entorpecentes é patente, por conseguinte.

O réu José Armando Costa poderá recorrer em liberdade, pois respondeu ao processo nesta condição.

Por outro lado, considerando a gravidade do delito cometido, o regime de pena imposto e mormente o fato de Wabner Moura da Silva ter sido preso em flagrante delito e encontrando-se detido até hoje, consoante orientação consolidada no Colendo Supremo Tribunal Federal, "se o réu, apesar de primário e de bons antecedentes, respondeu a ação penal, quando havia apenas o "fumus boni iuris", preso, após a prolação de sentença, surge a certeza que exclui a possibilidade do recurso em liberdade" (RJDTACRIM 13/181). No mesmo sentido: STF: RT 552/444, RTJ 77/125, 88/69; STJ: RT 664/326, 711/384, RSTJ 64/75 e 95-6. Logo, o réu Wabner Moura da Silva não poderá recorrer em liberdade, devendo ser recomendado na prisão em que se encontra, mesmo porque continuam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, como já exposto na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e nas que a mantiveram.

Ressalto que eventual detração penal (art. 387, § 2º do CPP) deve ser postulada, oportunamente, ao juízo das execuções criminais competente, o qual possui condições de aferir a presença dos requisitos legais, especialmente os de natureza subjetiva.

Neste sentido: "Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Preliminar. Nulidade das provas obtidas mediante atuação da guarda municipal. Prisão em flagrante. Ofensa a preceito Constitucional não verificado. Preliminar afastada. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos agentes de segurança. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Penas escorreitas. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da quantidade, nocividade e diversidade de droga apreendida. Inteligência do artigo 42 da Lei de Drogas. Inaplicável o redutor de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Regime fechado mantido. Pretensão à aplicação da detração penal (artigo 387, §2º, CPP). Competência do juízo das execuções penais. Recurso não provido" (TJSP; Apelação Criminal 1500272-11.2021.8.26.0542; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Carapicuíba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/01/2022; Data de Registro: 17/01/2022).

Por fim, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, declaro perdidos em favor da União os celulares e os valores descritos no auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, pois se tratam de instrumentos utilizados para a prática do delito e produto dele.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral.

Custas na forma da Lei.

P.I.C.

Araçatuba, 19 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA